

0072895-81.2015.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... judicial:

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAPROVA. CONFIGURAÇÃO. ACESSO A DADOS DE TELEFONE CELULAR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA CASSADA. DIREITO DE RESPONDER À AÇÃO PENAL EM LIBERDADE. CONCESSÃO. RECURSOPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao considerar ilícito o acesso direto da polícia a informações constantes de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0072895-81.2015.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0072895-81.2015.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 9/2015 - 1ª Seccional - Centro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURICIO LEAL JUNIOR e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Vistos

MAURÍCIO LEAL JÚNIOR e KELLY VASCONCELOS DE MELO , qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal , porque, segundo apurado, no dia 06 de fevereiro de 2015, em horário incerto, na Rua Martiniano de Carvalho, 851, nesta cidade e comarca da capital, os réus, agindo em concurso e com unidade de propósitos e desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante abuso de confiança, 34 (trinta e quatro) notebooks, marca Lenovo/X240, bem como 04 (quatro) notebooks, marca Lenovo/T440, pertencentes à empresa vítima Telefonica Brasil S.A., conforme notas fiscais a fls. 10/17, auto de exibição e apreensão a fls. 69 e auto de entrega a fls. 103.

A denúncia foi recebida, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação. Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual foram ouvidos o representante da vítima, duas testemunhas e, ao final, os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução criminal, em sede de memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia ofertada.

O assistente de acusação, em sede de memoriais, pugnou pela condenação dos réus nos termos da denúncia, haja vista a absoluta tipicidade da conduta dos réus, das provas de autoria e materialidade.

A defesa do réu Maurício, por sua vez, requereu, em caso de condenação, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa da ré Kelly pugnou, preliminarmente, pelo "reconhecimento da ilicitude das provas produzidas em desfavor da acusada, no que concerne ao acesso às conversas do WhatsApp do réu Maurício, em virtude de ilegalidade, haja vista terem sido obtidas sem autorização judicial. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação da pena mínima no regime aberto com substituição por restritivas de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não obstante as alegações das defesas, a absolvição de Maurício à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados. Por outro lado, absolvição da KELLY é medida que se impõe.

A materialidade restou cabalmente comprovada pelas notas fiscais a fls. 10/18 e a fls. 558/561, relatório de investigação a fls. 20/37, auto de exibição e apreensão a fls. 72, auto de entrega a fls. 103, laudo pericial a fls. 163/214, bem como pela prova oral produzida na fase investigativa e em juízo, sob o crivo do contraditório.

A autoria do réu MAURÍCIO também é inconteste.

O representante da vítima Telefônica SA, Itamir Maraton Nunes, ouvido em Juízo, relatou que à época dos fatos, a empresa possuía uma operação em que os novos funcionários advindos da Espanha recebiam equipamentos de trabalho como computadores, mouses e teclados. A chave de acesso onde eram guardados os equipamentos ficava sob a guarda da testemunha e outras duas pessoas. Disse que, em um dado momento, verificaram haver tijolos nas caixas de notebook. Passados alguns dias, a equipe procurou eventuais anúncios de vendas no site da OLX, ocasião que identificaram alguns anúncios pelo número de série dos equipamentos. O acesso à sala onde ficavam os aparelhos não tinha câmera. Informou que a ré Kelly era prestadora de serviço, bem como tinha conhecimento de onde os equipamentos eram guardados, e desconhece quem é o réu Maurício. Não soube dizer como chegaram às investigações que apontavam os réus como suspeitos.

A testemunha Antônio, ouvido em Juízo, relatou que viu um anúncio no site da OLX onde o réu Maurício colocou à venda alguns notebooks, que não possuíam nota fiscal. Interessado na compra, marcaram de se encontrar em um supermercado e fecharam negócio. Disse que não tinha conhecimento da origem ilícita das peças e que não existia nenhuma etiqueta que pudesse identificar os equipamentos como sendo da Telefônica S.A. No mesmo sentido, declarou em solo policial, que adquiriu 06 notebooks do réu Maurício.

A testemunha Lucas, ouvido em Juízo, prestador de serviço de uma empresa terceirizada da vítima (CPM Brax), relatou que a ré Kelly era coordenadora do site e controlava a entrada e saída de ativos do estoque, já o réu Maurício trabalhava para a empresa Telefônica. Com a transferência da ré, ele ficou responsável pelo prédio onde os equipamentos estavam armazenados. Ele levantou o inventário do estoque e encontrou divergências, ocasião em que acionou as empresas, onde foi instaurado um processo de investigação. Em paralelo às investigações, iniciou uma procura por eventuais anúncios de vendas que pudessem levar aos equipamentos furtados. Em dado anúncio na internet, encontrou peças à venda onde o anunciante informava que poderia conseguir 5 a 10 peças semelhantes por semana. Ato contínuo entrou em contato com o vendedor, se passando por um possível comprador, ocasião em que conseguiu o número de série de alguns aparelhos e, ao compará-los, percebeu que coincidiam com os aparelhos desviados da empresa. O anunciante disse que se tratava

de produto de revenda, que tinha adquirido de um terceiro, e repassou o número dele. Ao pedir o telefone do Maurício à ré Kelly, percebeu que se tratava do mesmo número que o anunciante Antonio Augusto Madeira de Paula o havia repassado.

Aproximadamente 35 peças foram subtraídas, causando um prejuízo, em média, de R\$157.000,00. Disse que a ré possuía a chave de acesso bem como era responsável por fazer o relatório do estoque, antes dele assumir a atividade.

A testemunha Fabricio, ouvido em Juízo, relatou que tomou conhecimento dos fatos quando ele e o Lucas fizeram o levantamento do inventário das máquinas. Comunicaram o fato ao Itamir, representante da Telefônica. Kelly era sua supervisora, e a mesma autorizava a retirada dos equipamentos da sala onde ficavam acondicionados. Trabalhavam na sala, onde a chave do estoque das peças furtadas ficava guardada, em média 8 pessoas, inclusive a ré. Não possuía contato com o réu Maurício.

O réu Maurício, interrogado em Juízo, relatou que trabalhava na Telefônica no setor de fibra óptica. À época dos fatos, Kelly havia fornecido a ele 4 (quatro) máquinas alegando que se tratava de produto de descarte sobressalente e sem origem ilícita. O réu anunciou a venda das máquinas na rede de internet e repasso uma parte da venda pra a ré. Disse que não tinha acesso à sala onde ficavam guardados os equipamentos e que, após a sua demissão, tomou ciência de que mais máquinas havia sido subtraídas.

A ré Kelly, interrogada em Juízo, negou os fatos haja vista que aconteceram após a sua transferência para outro prédio. Disse que repassou apenas dois computadores dentro do processo de troca de aparelhos da empresa. O primeiro equipamento foi entregue ao réu em fevereiro de 2015. Após um mês, entregou o segundo equipamento, haja vista o primeiro ter sido furtado. Disse que a chave que abria a sala de acesso onde estavam os computadores era de sua responsabilidade, todavia, outras pessoas também tinham acesso à ela. Negou que tenha recebido repasse de valores pela venda dos computadores efetuada pelo réu Maurício.

Preliminarmente, com relação à prova obtida em desfavor dos réus, no que concerne ao acesso às conversas obtidas mediante a perícia efetuada no celular do réu MAURÍCIO, assiste razão a Defesa da ré KELLY. Aportaram aos autos conversas pessoais do réu, extraídas de seu WhatsApp, bem como descrição dos contatos, mensagens de textos e conteúdo da memória do aparelho (fls 163/214). A prova produzida é ilícita, haja vista a flagrante violação ao direito material, bem como foi produzida sem autorização judicial para tanto.

Nesse sentido, inclusive, em reiteradas decisões, os Tribunais superiores decidem pela ilegalidade da prova no que concerne ao acesso às mensagens do WhatsApp sem autorização judicial:

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAPROVA. CONFIGURAÇÃO. ACESSO A DADOS DE TELEFONE CELULAR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA CASSADA. DIREITO DE RESPONDER À AÇÃO PENAL EM LIBERDADE. CONCESSÃO. RECURSOPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao considerar ilícito o acesso direto da polícia a informações constantes de aparelho celular, sem prévia autorização judicial. Precedentes. 2. Hipótese em que a autoridade policial realizou perícia no telefone móvel do acusado e obteve os registros telefônicos e o histórico de conversas via Whatsapp. 3. A afirmação do Juízo sentenciante de que a defesa não comprovou a ausência de consentimento do réu para a submissão de seu aparelho celular a exame pericial constitui indevida inversão do ônus da prova e, por esse motivo, deve ser desconsiderada (STJ, Sexta Turma, RHC 89385/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

Salienta-se, ainda, a impossibilidade de declaração de todo o acervo probatório produzido a partir da juntada do laudo, haja vista que, no ordenamento jurídico, em regra, são inadmissíveis as provas ilícitas bem como as derivadas das ilícitas, salvo quando evidenciados o nexo de causalidade entre umas e outras e ainda se as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente da primeira.

Em que pese a ilicitude da prova ilícita isolada, os depoimentos das testemunhas em Juízo, quando confrontados com os depoimentos em solo policial são harmônicos, bem como foram críveis em assegurar que KELLY detinha a responsabilidade da guarda das chaves onde ficavam acondicionadas as peças furtadas, haja vista a função de responsabilidade dentro da empresa como supervisora. Fato este que foi confirmado,

por ofício pela própria diretoria da empresa-vítima (fl 107).

A ré Kelly disse que, à época que estava responsável pelas chaves, confeccionava o inventário periodicamente, todavia, só era relatado ou documentado se algo estivesse fora da normalidade.

Por sua vez, a testemunha Luis afirmou que, poucos dias depois de assumir a função da KELLY, observou que alguns notebooks haviam sido subtraídos e logo informou ao superior ITAMAR, e procederam as investigações.

O réu também confessou os fatos e informou que KELLY o entregou 4 (quatro) aparelhos. Em troca, ele lhe repassou metade dos valores apurados com a venda e mais um aparelho.

Ademais, conforme provas obtidas nos autos, KELLY detinha a chave, que ficava guardada em uma gaveta. Nesta mesma sala, trabalhavam, em torno de 8 (oito) funcionários e, segundo a testemunha Fabricio, o local era vulnerável haja vista o fluxo de pessoas que lá passavam, sendo assim, qualquer pessoa poderia ter pego a chave sem a supervisão da ré.

Em interrogatório, a ré afirmou que apenas entregou dois computadores a Maurício e que o processo estava revestido de legalidade, pois, o primeiro foi entregue tendo em vista que o computador pessoal do réu estava lento e demonstrando defeitos e o segundo foi entregue porque o primeiro havia sido furtado. As duas entregas foram documentadas às fls 420/428).

Segundo corroborado pelos depoimento em juízo e em sede policial, a sala de acesso aos computadores não possuía câmera, apenas o corredor

O réu MAURÍCIO confessou parcialmente a ação delitiva, se limitando a dizer que KELLY o entregou 4 aparelhos alegando serem produtos de descarte e, com a venda, repassou metade dos valores à ela. Fato este que vem corroborado com o depoimento do comprador dos aparelhos, Sr. Antonio.

Ademais, a testemunha Luis disse que encontrou no site da OLX anuncios de vendas que levaram aos aparelhos furtados da empresa. Em contato com o anunciante,este afirmou que comprara de um terceiro, ocasião em que forneceu o número de telefone dele, quando percebeu que o número fornecido se tratava do telefone de MAURÍCIO.

A testemunha Antonio confirmou que comprou os aparelhos à venda no site da Olx/Mercado Livre de MAURÍCIO. Foi oficiado à empresa que, em resposta, forneceu relatório (fls 131) em que foi apontado a venda de um dos notebooks furtados.

Acerca do CPF da ré Kelly nada foi encontrado.

Assim sendo , o mosaico probatório é robusto ao apontar o réu MAURÍCIO como autor dos delitos imputados na denuncia. Por outro lado, com relação à ré KELLY, haja vista que único fato que aponta um possível conluio com o réu seria a guarda da chaves sob sua responsabilidade, que, quando confrontado com as demais provas, restou verificado não se tratar de acesso exclusivo.

'Estas são as provas colhidas e produzidas sob o crivo do contraditório e diante delas, não há dúvidas de que MAURÍCIO se utilizando da qualidade de funcionário da empresa vítima, com livre acesso ao prédio e a suas dependências, subtraiu, para si, em proveito próprio, pelo menos 5(cinco) de propriedade da empresa, restituídos à fl. 106.

Caracterizada, portanto, a infração a penal, a condenação do réu MAURÍCIO é medida que se impõe.

Com relação à ré KELLY, diante de tal contexto, ausente prova cabal e segura produzida judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no que tange à autoria do delito, a improcedência da pretensão punitiva estatal deve prevalecer, visto que ausentes elementos probatórios concretos o suficiente para embasar eventual condenação criminal do acusado pela prática do delito que lhe foi imputado da denúncia.

Inclusive, firme é a jurisprudência no sentido de que: "Para que subsista uma condenação e, mesmo para que ela seja imposta é preciso que a prova não dê azo a qualquer incerteza,mostrando-se límpida e firme. Qualquer dúvida já compromete o juízo da condenação".(TACRIM - AC - Rel. Juiz Camargo Sampaio - RT 549/348).

Deve-se deixar claro, ainda, que as declarações prestadas na fase administrativa, devem ser analisadas e sopesadas com as outras colhidas sob o crivo do contraditório, e tais provas, assim colhidas,não foram suficientes para embasar a

condenação da ré.

Com relação ao MAURÍCIO, passo a dosar a pena.

O réu é primário e não possui antecedentes criminais, portanto, fixo a pena base de 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase não há agravantes ou atenuantes a se considerar.

Na terceira fase também não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena.

Como não há nos autos provas da condição econômica do réu, fixa-se o dia-multa no mínimo legal estabelecido.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER a ré KELLY VASCONCELOS DE MELO, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e CONDENAR o réu MAURÍCIO LEAL JÚNIOR à pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) dias multa, calculados na base do valor unitário mínimo legal, por estar incurso no 155, §4º, inciso II (abuso de confiança) do Código Penal, que deverá ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Nos termos do disposto no art. 44 do Código penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo tempo da pena substituída e pena de prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos, a ser destinada a entidade pública ou privada com destinação pessoal, que deverão ser determinadas no Juízo da Execução, sem o prejuízo do pagamento das diárias mínimas estabelecidas.

Deixo de aplicar a pena restritiva em prol da vítima e no valor apontado do prejuízo, já que a pena restritiva deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta, sob pena de se desnaturar o benefício.

Deixo ainda de fixar valores relativos a eventuais danos morais sofridos pelo ofendido já que não há nos autos elementos sólidos para se fixar o montante, podendo a vítima, caso assim queira, valer-se das vias cíveis para obter tais valores.

Em caso de eventual descumprimento, o regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, sobretudo pela primariedade e bons antecedentes da acusada. Nos termos do disposto no art. 77, inciso III, do Código Penal, deixo de aplicar ao réu o "sursis".

Tendo em vista a espécie de pena aplicada e ainda o fato de que o réu permaneceu solto durante toda a instrução, não havendo motivos para decretar prisão cautelar, poderá recorrer em liberdade.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houver impugnação de alguma das partes.

Com a juntada dos cálculos aos autos, abra-se vista às partes para a devida ciência e eventual manifestação.

Condene ainda o réu ao pagamento das custas judiciais, que decorre de expressa previsão legal.

Com efeito, o Código de Processo Penal cuida do tema nos artigos 804 e 805e, no Estado de São Paulo, do assunto tratou a Lei Estadual nº 11.608/2003.

Assim sendo, poderá o condenado, caso demonstre preencher a hipótese legal, valer-se do quanto disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, o que se dará quando da execução.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 12 DA LEI N.º 1.060/50. AGRAVO DESPROVIDO. Mesmo sendo o réu beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do CPC, ficando seu pagamento sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos. 2. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado. 3.

Aggravamento regimental desprovido. (STJ, AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 14/06/2011).

Oportunamente, arquivem-se.

P.R.I.C

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA